

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8595/2553

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี  
นายเจ็ด สุขประเสริฐ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 285

ผู้เสียหายมิใช่ผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของจำเลย และคำว่า "ผู้อยู่ใต้  
อำนาจปกครอง" ตาม ป.อ. มาตรา 285 หมายถึง ความปกครองตามที่บัญญัติไว้ใน  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ตามพฤตินัย การที่จำเลยและภริยารับผู้เสีย  
หายมาอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา ผู้เสียหายมิได้อยู่ในความปกครองของจำเลย  
ตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่จำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งเป็นลูก  
เลี้ยง จึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่ผู้อยู่ในความปกครอง  
ตาม ป.อ. มาตรา 285

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 285

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา  
277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุก  
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำ

ข้าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีผู้อยู่ในความปกครอง จำคุกกระทงละ 9 ปี 4 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 18 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ผู้เสียหายมิได้เป็นผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของจำเลยกับนางสำเนียง แต่อาศัยอยู่ด้วย โดยจำเลยและนางสำเนียงเลี้ยงดูให้การศึกษาตลอดมา ขณะเกิดเหตุครั้งแรกผู้เสียหายอายุ 9 ปีเศษ และในครั้งที่สองอายุ 10 ปีเศษ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ซึ่งพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์ลักษณะการเบิกความของผู้เสียหายในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่ 31 มีนาคม 2548 แล้ว การเบิกความในตอนเช้ามีลักษณะที่สมด้วยเหตุผลมากกว่า อีกทั้งมีคำให้การที่ผู้เสียหายเคยให้ถ้อยคำมาก่อนสนับสนุนซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นความจริงดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ส่วนที่เบิกความแตกต่างตรงข้ามในช่วงบ่ายมีความเป็นไปได้มากกว่าผู้เสียหายเกิดความสงสารจำเลยที่อาจต้องรับโทษเพราะคำเบิกความของตน เพราะถึงอย่างไรผู้เสียหายก็ได้รับการเลี้ยงดูจากจำเลยและนางสำเนียงตลอดมา แม้ปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่กับนางปรารค์น้องสาวของจำเลยที่จังหวัดตรัง ที่เดินทางมาเบิกความจากจังหวัดตรังก็มาพักอาศัยอยู่กับจำเลย และผู้เสียหายเบิกความด้วยว่าไม่ต้องการให้จำเลยรับโทษจำคุก จึงน่าเชื่อว่าคำเบิกความของผู้เสียหายในตอนบ่ายมิได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริง จำเลยนำสืบโดยมีเพียงตัวจำเลยเบิกความว่าได้ตั้งใจเลี้ยงดูผู้เสียหายในฐานะลูกเป็นอย่างดีมาตลอด ไม่เคย

กระทำผิดทางเพศใด ๆ แก่ผู้เสียหาย โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน จึงเป็น  
คำเบิกความลอย ๆ ที่ไม่มีน้ำหนักจะฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ในประเด็น  
นี้ แต่มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าจำเลยกระทำความผิดสำเร็จหรือไม่ ประเด็นนี้ผู้เสียหาย  
เป็นผู้เดียวที่รู้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราสำเร็จหรือไม่ ผู้  
เสียหายให้การไว้ว่าจำเลยกระทำความผิดสำเร็จโดยสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปใน  
อวัยวะเพศของผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ทั้งสองครั้งแตกต่างจากที่เบิกความ  
ยืนยันว่าตั้งแต่จำเลยลวนลามทางเพศผู้เสียหายเมื่อปี 2538 จำเลยไม่เคยใส่อวัยวะ  
เพศเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายได้เลย ในการกระทำความผิดตามฟ้องทั้งสอง  
ครั้ง จำเลยก็พยายามจะสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไป แต่ไม่อาจใส่เข้าไปได้ แม้โจทก์จะมี  
นายแพทย์วรากร แพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายเบิกความประกอบผลการตรวจว่า  
พบรอยฉีกขาดเก่าที่มุมบนและมุมล่างของเยื่อพรหมจารี น่าจะเกิดจากการมีวัตถุ  
ของแข็งสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการร่วมประเวณี ซึ่ง  
แม้หากเป็นข้อเท็จจริงว่าเกิดจากการร่วมประเวณี ก็มิได้หมายความว่าผู้ร่วมประเวณี  
กับผู้เสียหายต้องเป็นจำเลย เพราะตัวผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้าน  
ว่า เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายเมื่อตอนเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งเป็นเวลาก่อน  
การตรวจของนายแพทย์วรากร การกระทำชำเราตามฟ้องก็เกิดก่อนการตรวจของ  
นายแพทย์วรากรถึงเกือบ 2 ปี และ 3 ปี เวลาที่เนิ่นนานเช่นนี้ จะสันนิษฐานหรือ  
ถือว่าเยื่อพรหมจารีของผู้เสียหายที่มีรอยฉีกขาดเก่าเกิดจากการกระทำของจำเลยยัง  
ไม่สมด้วยเหตุผลและไม่เป็นธรรมแก่จำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เสียหายเบิก  
ความว่ามีบุคคลอื่นร่วมประเวณีกับผู้เสียหายมาก่อนตรวจด้วย ผู้เสียหายก็เบิกความ  
ยืนยันว่า จำเลยไม่เคยสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายได้สำเร็จ  
พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบสำหรับประเด็นนี้ยังมีความสงสัยตามสมควรว่า  
จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายสำเร็จหรือไม่ จำเป็นต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย  
นั้นแก่จำเลย คดีคงฟังได้แต่เพียงว่าจำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย

เท่านั้น ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นฎีกาว่า ผู้เสียหายมิใช่ผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของจำเลย และคำว่า "ผู้อยู่ในความปกครอง" ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 หมายถึง ความปกครองตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ตามพยาน การที่จำเลยและภริยารับผู้เสียหายมาอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา ผู้เสียหายมิได้อยู่ในความปกครองของจำเลยตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่จำเลยพยายามกระทำซ้ำเราผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกเลี้ยง จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำซ้ำเราแก่ผู้อยู่ในความปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยตามมาตรานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง (เดิม), 80 จำคุกกระหนงละ 4 ปี 8 เดือน รวม 2 กระหนงจำคุก 8 ปี 16 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(สุรศักดิ์ กิตติพงษ์พัฒนา-วรพจน์ วิไลชนม์-อนันต์ ชุมวิสูตร)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายธีระยุทธ สุภะกลิน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1776/2548

ต้น

หมายเหตุ